

1511604-10.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511604-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511604-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130124/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 24944140 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2130124 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO APARECIDO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

CARLOS ALBERTO APARECIDO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, cc. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta de 16h15min, na Praça Getulio Vargas, sem número, e na rua Professor Cosme Deodato Tadeu, altura do numeral 90, Lajeado, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo 30 invólucros plásticos contendo 36,3 gramas de maconha e 108 invólucros plásticos contendo 58,3 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o acusado apresentou defesa prévia, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos (pág. 90).

Recebida a denúncia (págs.91/95), durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, requereu: nulidade da prova produzida tendo em vista que a prisão foi feita por guardas civis metropolitanos; fixação da pena no mínimo legal; aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da lei 11.343/06 em sua fração máxima; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; desclassificação da figura típica denunciada para a prevista no artigo 28 da mesma lei; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; regime de cumprimento diverso do fechado; e, por fim, seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Por primeiro, afasto a pretensão da Douta Defesa, que sustenta ilegalidade da diligência realizada por integrantes da guarda municipal.

Com efeito, é certo que aos guardas municipais cabe a atuação essencialmente vinculada à defesa do patrimônio municipal, o que não lhes retira legitimidade para efetuar prisão em flagrante de indivíduo surpreendido praticando crime, nos termos do que estabelece o artigo 301 do Código de Processo Penal, dentro do princípio de autodefesa da sociedade.

Logo, legítima a prisão em flagrante, bem como a prova dela decorrente, de forma que não há que se falar em nulidade.

Nesse sentido: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal - aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ. Agravo regimental desprovido." (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.565.524 - MS (2019/0249396-3)RELATOR : MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE- DJE 12/12/2019).

"...Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado no caso dos autos, a atuação dos agentes municipal está respaldado comando legal do art.301 do Código de Processo Penal (STJ, HC nº 549805/SP, 5ª T, rel Min. Joel Ilan Paciornik, j.11/02/2020).

Assim, o que se verifica é que o acusado foi surpreendido portando drogas variadas e fracionadas para fins de mercancia, estava em situação de flagrante delito, o que permite a qualquer do povo proceder a prisão, inclusive o guarda municipal, que não é excluído da disposição legal em questão.

No mérito, é procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 08/10); auto de exibição e apreensão (pág. 12); imagem das drogas apreendidas (págs. 13/15); laudo de constatação (págs. 17/20); laudo de exame químico-toxicológico (páginas 82/84), que apontou para a presença de tetrahydrocannabinol e cocaína nas substâncias analisadas; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado

admitiu que portava as drogas apreendidas para fins de mercancia. Narrou que : "quanto aos fatos, optou por responder ao que lhe fosse perguntado. Confessou que estava na promoção do tráfico de drogas. Nada mais disse." (pág. 07).

Em Juízo, entretanto, negou o cometimento do crime.

Afirmou que é usuário de cocaína e estava no local dos fatos para adquirir a droga para consumo.

Esclareceu que portava a quantia de dez reais, chegou a pedir uma porção de cocaína ao traficante, momento em que foram abordados por policiais.

Desta forma, o traficante correu e jogou uma sacola ao solo.

Foi abordado juntamente com outros usuários, e acabou responsabilizado pelas drogas apreendidas em razão de ostentar envolvimento criminal anterior pelo mesmo crime.

Acrescentou que confessou o crime na delegacia de polícia, o que fez porque nunca havia passado pela mesma situação, e ficou com medo.

Essa singela e inconsistente negativa de autoria não é merecedora de nenhuma credibilidade, restou isolada nos autos, e desacompanhada de demonstração probatória de veracidade.

Ao contrário, a confissão extrajudicial se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, sobretudo diante da quantidade de entorpecentes encontrada sob responsabilidade do réu e do minudente e insuspeito relato dos agentes responsáveis pela diligência.

Os guardas civis responsáveis pela diligência apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.

Narraram, em uníssono, que patrulhavam pela região dos fatos, notório ponto de venda de drogas. O acusado estava parado na via, acompanhado de outro indivíduo, e ambos, quando notaram a viatura empreenderam fuga, o que lhes causou suspeitas. Foram atrás dos suspeitos e os abordaram. O acusado portava uma pochete e no interior dela havia drogas variadas e fracionadas, bem como uma quantia em dinheiro. O indivíduo que acompanhava o acusado não portava nada ilícito, foi conduzido ao distrito policial e dispensado pela autoridade.

Questionado, informalmente, o acusado admitiu que promovia a mercancia no local. Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do crime, sendo incontroversa a autoria.

Interrogado em solo policial, o acusado confessou a imputação, admitindo que portava as substâncias apreendidas em seu poder, e que destinadas a mercancia.

No contraditório, entretanto, negou a imputação e apresentou singela e inconsistente negativa de autoria, cuja veracidade nem de longe comprovou, como lhe competia fazer, nos termos do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o réu foi surpreendido enquanto trazia consigo drogas diversificadas e fracionadas, prontas para o comércio, não apresentando justificativa convincente quando instado, restando evidente que estava no local realizando o comércio espúrio.

E os esclarecimentos apresentados pelos guardas civis, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente, que sequer conheciam.

Como qualquer testemunha, prestaram compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas".(TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Enfim, o conjunto probatório é bastante sólido e incrimina sobremaneira o réu, ensejando uma condenação segura.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como as drogas estavam acondicionadas - 30 invólucros plásticos de maconha e 108 de cocaína (imagens juntadas às págs. 13/15) -, e as circunstâncias da prisão em flagrante afastam qualquer dúvida quanto a destinação, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da lei especial, até porque o acusado não reivindicou a posse dos entorpecentes para consumo próprio.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343). "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Demonstrada a ocorrência do delito, e comprovada a autoria, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

O acusado registra processo em andamento, mas é tecnicamente primário.

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, torno definitiva a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução por força de circunstância atenuante (Súmula 231 do STJ).

Não estão presentes os requisitos legais para a redução de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06, como muito bem observou o representante do Ministério Público.

Com efeito, conforme se verifica do quadro probatório produzido, o acusado já foi flagrado e preso em flagrante pelo mesmo crime, o que se deu em 13/04 passado (pág. 70). Entretanto, menos de um mês depois, foi flagrado no mesmo local, praticando o mesmo crime, o que revela habitualidade.

Não bastasse, no momento em que foi abordado, portava as drogas e também R\$ 66,00, o que revela que já havia vendido inúmeras porções dos entorpecentes. Questionado, informalmente, confessou aos policiais que já havia vendido drogas no local em outras oportunidades.

Ademais, ao que tudo indica, o acusado não exerce qualquer atividade lícita - até porque não produziu qualquer prova a respeito, não sendo desarrazoado presumir que faz da traficância seu meio de vida.

Por fim, portava mais de cem porções de cocaína (pág. 13), droga altamente nociva e viciante, o que compromete sobremaneira a saúde pública.

Assim, ausente o requisito legal consistente em não se dedicar a atividade criminosa em questão, não estão presentes os requisitos para aplicação do redutor de pena pleiteado pela Douta Defesa (art. 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra CARLOS ALBERTO APARECIDO DE SOUZA, R.G. Nº 56.548.235, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90.

Por força da gravidade do crime aqui tratado, considerado hediondo, o acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. Por se tratar de crime hediondo, que compromete a saúde pública, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena - Cabimento - Materialidade e autoria comprovadas - 45 (quarenta e cinco) microtubos plásticos encontrados no exato local em que o réu se abaixou, próximo de sua carteira que também foi dispensado pelo Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu - Aplicação da agravante da reincidência - Não aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO PROVIDO" (TJSP; Apelação 0001725-63.2017.8.26.0540; Relator(a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

"ENTORPECENTE. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime de tráfico. Circunstâncias da abordagem e quantidade de entorpecente apreendido indicando destinação comercial, segundo os critérios do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Condenação por tráfico que se impõe. Dosimetria. Básicas que partem dos mínimos legais, sendo acrescidas de um quinto, na segunda fase, pela dupla reincidência, a qual, aliás, impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/0. Regime fechado necessário, sendo incogitável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido, com determinação" (TJSP; Apelação 0004107-35.2017.8.26.0635; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

Pelos fundamentos acima expostos, bem como por tudo quanto produzido no contraditório, presentes os requisitos legais, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada, nos termos do que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, a medida se mostra necessária, inclusive, para assegurar o cumprimento da pena aplicada.

É certo que o réu está preso desde 12 de maio passado, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), porque eventual progressão é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c" - detração penal, da Lei nº 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nos termos do artigo 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, ou seja, R\$ 66,00 (sessenta e seis reais) relacionada no auto de exibição e apreensão (pág. 12), uma vez que oriunda do comércio espúrio em questão.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA